

1500013-25.2022.8.26.0172

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HALLANA DUARTE MIRANDA

Comarca: Eldorado

Foro: Foro de Eldorado Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DEDESCCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Eldorado

Foro de Eldorado Paulista

Vara Única

Rua Professor Francisco Canto, 14, Eldorado-SP - cep 11960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500013-25.2022.8.26.0172 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500013-25.2022.8.26.0172

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2014011/2022 - DEL.POL.ELDORADO, 22474631 -

DEL.POL.ELDORADO, 2014011 - DEL.POL.ELDORADO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ADEMILSON DIAS RAFAEL

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HALLANA DUARTE MIRANDA

I - RELATÓRIO

ADEMILSON DIAS RAFAEL foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 16 de janeiro de 2022, por volta das 23 horas e 40 minutos, na Rua Presbítero Alício Freitas de Oliveira, nº 306, Vila Nova Esperança, nesta Cidade e Comarca de Eldorado/SP, trazia consigo, para fins de tráfico de entorpecentes, 04 porções de cocaína, e guardava, com a mesma finalidade, 0 porções de maconha, com peso de 32 gramas, 36 porções de cocaína, totalizando 41 gramas 05 porções de crack, pesando 06 gramas, além de mais 07 porções de maconha, substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da denúncia às fls. 65/66:

Segundo apurado, o denunciado estava na companhia de diversas pessoas que deixaram

o local com a aproximação da polícia militar. ADEMILSON tentou fugir, entretanto foi abordado no interior de sua residência.

Destarte, foram localizados os entorpecentes apreendidos nos autos, parte na sua posse e parte na sala de televisão e banheiro da morada, além de R\$ 65,00 em dinheiro.

Assim, a quantidade e variedade de drogas encontradas em seu poder, a forma de acondicionamento, o modo de embalagem e armazenamento, o comportamento, as notícias recebidas pelos policiais militares, o dinheiro que trazia, além das demais circunstâncias, não deixam dúvidas de que os entorpecentes se destinavam à entrega ao consumo de terceiros, por meio de tráfico ilícito.

Consta dos autos, Auto de prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/06), Termo de Depoimento (fls. 07/09), Termo de Declarações (fls. 10), Interrogatório (fls. 11/12), Nota de Culpa (fl. 13), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14/15), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 16/17), Requisição de Substância Entorpecente (fl. 18), Fotos (fls. 24/27 e 29/35), Requisição de Objeto (fl. 90), Laudo Pericial (fls. 91/95), Relatório Final (fls. 103/105), Folha de Antecedentes Criminais (fls. 236/245) e Certidão de Feitos Criminais (fls. 246/250).

Recebida a denúncia em 17 de janeiro de 2022 (fls. 67/72)

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação às fls. 114/116.

Em 01 de julho de 2022 foi realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e procedeu-se com o interrogatório do réu.

O Ministério Público, em alegações orais, pugnou pela procedência da pretensão acusatória e teceu considerações sobre a dosimetria das penas.

A d. Defesa apresentou memoriais às fls. 269/273, pugnou pela absolvição do acusado em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 para o constante no artigo 28 da Lei de Drogas,

II - FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, faz-se imperiosa a análise a seguir.

No caso, os policiais narraram em juízo que o acusado teria dado seu consentimento para que a equipe entrasse no imóvel, mas, (i) quanto à voluntariedade do consentimento, o relato do réu é no sentido de que o policial sacou a arma e solicitou que abrisse a porta.

Trata-se de situação que, inequivocamente, provoca intimidação e temor – mesmo que sem intenção dos policiais –, o que fulmina a voluntariedade do consentimento eventualmente declarado para a execução de medidas restritivas de direitos fundamentais em tais circunstâncias.

Todavia, há que se estabelecer que o relato do preso foi absolutamente isolado no contexto da produção da prova, já que a versão não se coaduna com o relato de ambos os policiais.

Em regra, vale registrar que recai sobre a acusação o ônus de comprovar a hipótese acusatória com elevadíssimo grau de probabilidade (e não sobre o acusado o ônus de comprovar a sua inocência).

Contudo, no que concerne à voluntariedade do agente, o relato de que teria sido a ele apontada um arma enquanto estava na janela de sua casa e que a polícia teria feito ameaças prévias, não há provas nos autos, de forma que seu relato sobre ter havido ingresso à força fica enfraquecido diante de não terem sido arroladas testemunhas.

Veja-se que não é qualquer alegação que pode gerar a dúvida do Juízo de que os policiais estavam agindo licitamente, muito embora a Jurisprudência venha cada vez mais firme no sentido de que incumbe aos órgãos acusatórios apontarem a regularidade da sua conduta.

Por isso, a simples palavra, sem contextualização, não pode levar a crer que toda a conduta policial está sustentada em nulidade. O Juízo procura analisar cuidadosamente os relatos e reconhecer a nulidade apenas naqueles em que o conjunto da abordagem aponte para a prática de irregularidades.

Isso porque as decisões precisam ser fundamentadas, ou seja, conectar fatos colhidos em audiência e fundamentos jurídicos.
Por isso, ENTENDO VÁLIDA a colheita de provas, neste caso.

DO MÉRITO

A materialidade do tráfico de drogas está bem comprovada nos autos por intermédio do Auto de prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/06), Termo de Depoimento (fls. 07/09), Termo de Declarações (fls. 10), Interrogatório (fls. 11/12), Nota de Culpa (fl. 13), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14/15), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 16/17), Requisição de Substância Entorpecente (fl. 18), Fotos (fls. 24/27 e 29/35), Requisição de Objeto (fl. 90), Laudo Pericial (fls. 91/95), Relatório Final (fls. 103/105) e, sobretudo pela prova oral, colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O Laudo Pericial analisou 06 (seis) itens, concluindo: Item 1 - [...] foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Item 2 - [...] foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Item 3 - [...] foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Item 4 - [...] foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Item 5 - foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Item 6 - foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).

Interrogado, o réu negou a prática delitativa, disse: No dia 16 de janeiro, estava junto com minha namorada Eliene e Rafaella. Nós fazemos uso de maconha e estávamos fumando. Em seguida, o policial Eder, Valdoski e Silva me abordaram da janela e solicitaram para que abrisse a porta. Minha namorada abriu a porta e os policiais começaram a realizar busca na casa, afirmando que estavam procurando drogas. Na bolsa da Rafaella encontraram um baseado de maconha e na de Eliene acharam dois baseados de maconha. Os policiais avistaram meu alvará e a carteirinha da condicional, falaram que eu ia voltar rápido para a cadeia, além disso, agrediram-me. Na delegacia, fui informado que encontraram outras drogas na minha residência, porém, não entendi o motivo, pois portava apenas um cigarro de maconha. Minha casa é a última do morro e a rua fica distante. O policial Eder colocou a arma na minha cabeça e mandou abrir a porta, assim pedi para Eliene abrir a porta. Desconheço o crack apreendido, a entorpecente foi apresentada somente na delegacia.

A testemunha Rafael Dos Santos Silva, Policial Militar, asseverou: Durante o patrulhamento, uma testemunha nos informou que estava ocorrendo tráfico de drogas no local dos fatos. Chegando à localidade, avistamos aproximadamente seis indivíduos, entre eles rapazes e meninas. Solicitamos apoio, ocorre que, quando voltamos, apenas o acusado se encontrava no local e, ao avistar a viatura, empreendeu em fuga em direção a sua residência. Fomos atrás dele e pela janela o avistamos junto com duas meninas. O réu viu os policiais, disse 'Perdi, Perdi' e solicitou que uma das meninas abrisse a porta. Realizamos a revista pessoal do acusado e encontramos com ele quatro pinos de cocaína. Atrás da pilastra da pia do banheiro encontrei uma sacola com uma quantidade de drogas entre elas cocaína e crack. Na bolsa da Rafaella foi encontrado uma quantidade de drogas. Ademilson disse que toda a drogas que fosse encontrada era dele. Além, das drogas, encontramos uma quantia de aproximadamente sessenta e cinco reais.

A testemunha Joaquim Maurício Grothe Valdoski, Policial Militar, disse: "Recebemos uma denúncia que estava ocorrendo tráfico de drogas no local dos fatos. Próximo à residência do acusado, localizamos cinco homens e duas meninas e, devido ao número de pessoas, solicitamos apoio de outra viatura. Quando retornamos ao local, as pessoas não estavam no local. Mas Ademilson estava na escada e quando viu a viatura

correu para a residência. Fomos atrás dele, o policial Silva olhou pela janela da residência e de pronto o réu falou 'perdi', abriu a porta da casa e franqueou a entrada. Realizamos revista pessoal e localizamos em posse do acusado quatro eppendorf de cocaína. Na sala, achamos porções de maconha e um pouco de dinheiro. No banheiro, encontramos um pacote contendo cocaína, pedras de crack e saquinhos de 'chup chup'. O réu disse que toda a droga que fosse encontrada seria dele. No local havia duas adolescentes que tínhamos avistado anteriormente. Na bolsa da Rafaela foi encontrado um cigarro de maconha, um pouco de maconha dichavada e uma porção de maconha. Ela admitiu a posse do cigarro e da entorpecente dichavada, porém negou a propriedade da porção de maconha, alegando que Ademilson teria colocado na sua bolsa". Às perguntas da defesa, respondeu que o réu não tinha anotações relacionado às drogas

Durante a instrução processual, a prova oral, consistente nas declarações das testemunhas, consubstancia sólido elemento de convencimento a demonstrar que as condutas imputadas ao acusado existiram e foram verídicas.

Evidencia-se que o acusado confirmou que foi abordado pelos policiais e que utilizava apenas um "cigarro de maconha", negando apenas a propriedade das demais drogas apreendidas.

Ocorre que a versão de que as drogas lhe pertenciam, em todos os momentos se comprova (art. 33 da Lei de Drogas), em especial, pelos depoimentos das testemunhas.

Conclui-se que as entorpecentes eram destinadas à traficância, considerando a variedade de drogas recolhidas, a forma de acondicionamento e dinheiro em espécie encontrado junto às drogas.

Destaca-se que o depoimento das autoridades públicas tem presunção de veracidade. E, neste caso, não há qualquer elemento que possa enfraquecer a versão de que as drogas foram apreendidas.

Do contrário, seria pressupor que o material foi implantado no local ou que as informações prestadas em Juízo são falsas, o que seria não condizente com as versões apresentadas.

Logo, do conjunto probatório coligido aos autos não pairam dúvidas de que, de fato, as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam e eram destinadas à traficância.

No tocante à tese defensiva da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para o consumo, resta ser afastada. Vejamos:

No caso em pauta, é importante frisar a diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidas (fl. 14):

As substâncias entorpecentes, segundo estudos, agem diretamente no sistema nervoso. Com isso, do ponto de vista científico, considerando que o bem jurídico tutelado pelo crime disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006 é a saúde pública, consequentemente, para que a natureza da droga seja considerada grave, tal constatação deve se basear em informações sobre a nocividade de cada entorpecente para a saúde de seu usuário, como danos gerados nos órgãos, grau de dependência, agressividade no indivíduo, portanto, não há dúvidas em relação à autoria do delito de tráfico de drogas.

Cumprе destacar que se tem reiteradamente decidido que para a caracterização do delito previsto no artigo 33, não se faz necessário seja o infrator colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Tratando-se de crime de mera conduta, ter em depósito, guardar, transportar, trazer consigo, não importa a modalidade, dessa forma, basta que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal.

Segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020)".

Assim, não restam dúvidas que o acusado faz do tráfico de drogas o seu modo de vida, e, ainda, todas as provas colhidas e contidas nos autos, atestam a prática delitiva do acusado.

Da aplicação do privilégio

Importante ainda ressaltar que o réu é reincidente, impossibilitando a aplicação no disposto no artigo 33§ 4º da Lei nº 11.343/2006. Nesse sentido inclina-se a jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há como ser aplicada a minorante prevista no § 4º do art. da Lei de Drogas em favor do recorrente, haja vista a vedação legal expressa da concessão dessa benesse aos acusados reincidentes. 2. O reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Não há falar, portanto, em bis in idem. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido

Destarte, de tudo o que foi exposto, tem-se que o acervo probatório é vasto e suficiente para ensejar a condenação do acusado na conduta de tráfico de drogas, sem a forma privilegiada.

III - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Passo à individualização das penas em consonância com o artigo 68 do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria das penas devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, as suas circunstâncias e consequência, e o comportamento da vítima.

1º fase: O sentenciado apresenta uma circunstância negativa consistente naquela prevista no art. 42 da Lei de Drogas, relativamente à natureza e quantidade. Por terem sido recolhidas mais de uma substância entorpecente, reputo essa circunstância como negativa. Considerando a diversidade das substâncias, importa em acréscimo de 1/6 (um sexto) calculado sobre a pena em abstrato. Assim sendo, quanto ao crime de tráfico de drogas FIXO a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2º fase: Na segunda fase da dosimetria das penas o sentenciado incide na agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, podendo ser considerado reincidente, conforme autos nº 0001429-25.2010.8.26.0172, que transitou em julgamento antes da prática dos fatos ora apurados, conforme certidões de fls. 247. A agravante importa acréscimo de 1/6 sobre a pena anteriormente fixada. Fixo a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

3º fase: Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena. Fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, tal qual acima alinhavado, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o fechado, sobretudo porque amplamente desfavoráveis as circunstâncias judiciais e a reincidência. Ausentes informações sobre a situação econômica da acusada, o valor do dia-multa deve corresponder ao mínimo legal.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR ADEMILSON

DIAS RAFAEL, qualificado nos autos, pelo crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Inviável o deferimento dos benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal, eis que os acusados não preenchem os requisitos legais, sobretudo em vista das circunstâncias judiciais desfavoráveis e o quantum da pena.

INDEFIRO o direito do réu apresentar recurso em liberdade, mantendo a prisão decretada nestes autos, pelos fundamentos já expostos e objeto de reavaliação noventenária, nos termos de recente decisão, cuja fundamentação reitero.

EXPEÇA-SE guia de execução provisória.

Providencie-se, também, após o trânsito em julgado, a expedição da guia de recolhimento para execução definitiva (artigos 105 e 106, da Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210/84, artigo 703 do Código de Processo Penal e artigos 467 a 469 das NSCGJ); as comunicações de estilo ao IIRGD e à Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição da República).

Condeno a ré a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Eldorado, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA